

1504233-24.2020.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Apropriação indébita Previdenciária
Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS
Comarca: Mairiporã
Foro: Foro de Mairiporã
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LICENÇA DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal disponha que "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", o preceito contido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504233-24.2020.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504233-24.2020.8.26.0338

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE BERNARDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

ALEXANDRE BERNARDES, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 168, §2º, inciso II, c.c. artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, porque, supostamente, em data incerta, porém entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, por 13 vezes, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o réu, teria se apropriado de coisa alheia móvel, consistente nos valores de benefício de prestação continuada, totalizando a quantia de R\$ 13.634,00 (treze mil seiscentos e trinta e quatro reais), de que teve a posse em razão do exercício da função de curador de seu irmão e vítima A.B.deS., consoante fls.57. Conforme a denúncia (fls.64/65) e, segundo o apurado, A.B.deS. é acometido de patologias (esquizofrenia e dependência química) e obteve o benefício de prestação continuada junto ao INSS, sendo o réu seu curador. Assim, na condição de curador, o réu, hipoteticamente, realizava os saques do benefício, todavia não empregava os valores em favor da vítima, apropriando-se dos valores. Ocorre que, a vítima foi internada para tratamento e depois passou a residir na Residência Terapêutica de Mairiporã, no que se descobriu que o denunciado, em tese, não revertia os valores em favor da vítima, inclusive deixando de fornecer itens pessoais e de asseio pessoal. Destarte, o CAPS comunicou tais fatos ao Ministério Público. Durante a investigação, o Instituto Nacional do Seguro Social encaminhou informações sobre o benefício, indicando que continua ativo. Assevera, a denúncia, que todos os benefícios foram sacados pelo réu, entre 01/01/2020 e 31/01/2021 (13 meses), de

acordo com fls. 57, que não os repassou à vítima, tampouco prestou contas, mesmo após ser instado também pela equipe do CAPS. Assim, a vítima teria sofrido prejuízo mínimo de R\$ 13.634,00 (treze mil seiscentos e trinta e quatro). Documentos juntados às fls.66/69.

Decisão às fls.74/75 em que recebeu a denúncia.

Regularmente citado (fls.83), o réu, por intermédio de advogada dativa, apresentou defesa prévia às fls.88/89, negando as imputações que lhe são atribuídas e reservando-se no direito de provar sua inocência durante a instrução processual, por fim, arrolou as mesmas testemunhas do órgão ministerial.

Decisão às fls.93/94 em que ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.128/129), foi ouvida a vítima, testemunhas e, em seguida, decretada a revelia do réu, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu como incurso no artigo 168, §1º, inciso II, c.c. artigo 71, "caput", ambos do Código Penal. No tocante a dosimetria da pena, requereu que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, ante a culpabilidade exacerbada, circunstâncias do crime e consequências para a vítima; na segunda fase, não há causas atenuantes ou agravantes; na terceira fase, pleiteou pela aplicação da causa de aumento do artigo 71, "caput", bem como do inciso II, §1º, do artigo 168, ambos do Código Penal. Em relação ao regime, requereu o inicial aberto, mas entendeu incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão do processo.

A d. defesa, por seu turno, pugnou pela não aplicação da revelia ao réu e, ainda, pugnou pela absolvição do denunciado, pois apresentaria provas de sua inocência em audiência.

Folha de Antecedentes às fls.121/122.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, destaco se encontrar presente exceção à identidade física do juiz, tendo em vista que a DRA DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA se encontra em licença saúde. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LICENÇA DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal disponha que "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", o preceito contido no referido dispositivo legal não pode ser aplicado de maneira absoluta, visto que a prestação jurisdicional dos togados investidos na competência para a apreciação e o julgamento de causas criminais passaria a ser, necessariamente, ininterrupta, impedindo-os de se afastar temporariamente de suas funções, seja por motivo de férias, de licença médica, de convocações, seja, até mesmo, de progressão funcional, o que é inerente à carreira. 2. Em razão da ausência de outras normas que regulamentam o disposto no referido artigo, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a mitigação do aludido princípio nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito. Aplica-se, por analogia (permitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal), o art. 132 do Código de Processo Civil. 3. O rol constante no art. 132 do CPC não é taxativo - haja vista a expressão "afastado por qualquer motivo", contida no caput -, razão pela qual a substituição é admitida também na hipótese de licença de saúde, tal como ocorreu no caso. 4. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 5. O Tribunal de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo

regimental não provido. (Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. AgRg no Agravo em Recurso Especial 1579227/MG (2019/0270624-1). Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 28/04/2020).

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo ofício requisitório para instauração de inquérito policial (fls. 04/05), Relatório do CAPS (fls.06/09, 38 e 66/69), Relatório Final (fls.18/19 e 59), Termo de Declarações (fls.41 e 43/44), Relatório do INSS (fls.55/57), Certidão de Objeto e Pé do processo 0004713-04.2005.8.26.0338 (fls.70/72), Ofício do processo 0004713-04.2005.8.26.0338 (fls.73), bem como pela prova oral colhida. Logo se vê, é certa a existência do objeto material coisa alheia móvel, qual seja, a quantia de R\$ 13.634,00 (treze mil seiscentos e trinta e quatro reais), de propriedade da vítima A.B.deS., sendo nítida a lesão ao bem jurídico patrimônio.

De outra banda, a prova se revela idônea para demonstrar a autoria, eis que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial, restando isolada a tese defensiva.

Com efeito, a vítima A.B.deS., declarou, em juízo, que, o réu era seu curador; ficou internado por um tempo no Juqueri; recebia visitas apenas de sua mãe; o réu lhe entregava entre R\$ 50,00 (cinquenta reais) e R\$ 100,00 (cem reais), por mês; o dinheiro não era o suficiente; não tem contato com o réu; Cláudio cuidava dele no CAPS e fazia compras..

A par disso, a testemunha Rita Carla da Silva Oliveira, Assistente Social, explanou que, A.B.deS. é interno da residência terapêutica; o réu é curador da vítima; ficou acordado que o réu receberia o benefício e levaria para a vítima; o coordenador da época, Cláudio, referia, nas reunião de equipe, que não conseguia contato com o réu e ele não cumpria o dever de levar o dinheiro mensalmente; às vezes, ou quando muito pressionado, o réu levava R\$ 500,00 (quinhentos reais), valor parcial do benefício; a vítima possui grande demanda para comprar itens pessoais e determinados alimentos, como produtos de beleza e doces; tentava contatar o réu, todavia não conseguia; decidiram, em equipe, fazer o relatório e informar o Ministério Público; a clínica é mantida pela Prefeitura, não sendo preciso pagar pela moradia; o réu foi até o CAPS e a questionou por que havia feito o relato para o Ministério Público; o réu falou que processaria as pessoas que haviam assinado o relatório; o ocorrido se deu em 03 de Fevereiro de 2022; indagou o réu por que não atendia as ligações e ele respondeu que não atende ligações a qual não possui o contato salvo; segundo Cláudio, o réu, em algumas ocasiões, levava doces para a vítima; o réu lhe contou que está construindo uma casa para a vítima e que possui recibos, mas não iria apresentar no processo; o réu lhes procurou pois o benefício foi bloqueado; o denunciado citou que "não vou atrás, o curador dele sou eu, e ele vai ficar sem o benefício" (sic); a vítima possui restrições para sair; quando o réu deixava algum valor, Cláudio acompanhava a vítima; o réu fazia depósitos, contudo não sabe informar se eram realizados na conta de Cláudio; Cláudio era funcionário de uma empresa terceirizada e não trabalha mais no local.

Igualmente, a testemunha Cláudio Donizetti Gonçalves dos Reis, declarou que, a vítima está na residência terapêutica que coordenou; requisitava, constantemente, o dinheiro da vítima, pois A.B.deS. possuía um perfil muito solicitante, principalmente em relação ao benefício; a vítima tem conhecimento da existência do benefício e que está na posse do irmão; algumas vezes, o réu levou o dinheiro; registrou a saída da quantia; o valor que o réu entregava não era integral; acredita que o réu tenha levado o dinheiro 4 vezes, entre R\$ 300,00 (trezentos reais) e, no máximo, R\$ 500,00 (quinhentos reais); conversou com o réu; o réu alegou que estava construindo uma casa para a vítima e o dinheiro era investido na construção; o réu nunca apresentou recibos; quando tentava contato, o denunciado lhe respondia poucas vezes; o réu realizou o depósito uma vez em sua conta, no valor de R\$ 350,00; registrou a entrada e saída da quantia; todos os valores eram devidamente documentados, mesmo contra a vontade do denunciado, que dizia que não

era necessário.

Ainda, a testemunha Maria José da Silva, aduziu que, trabalhou no CAPS por um período e percebeu que o réu não atendia as ligações que realizavam; foi efetuada visita domiciliar no endereço que possuíam, mas não o encontraram; soube que o réu entregava um valor parcial no serviço de Residência Terapêutica, porém não era contínuo; o réu não entregava valores no CAPS; não conheceu o réu pessoalmente e nunca falou com ele por telefone.

Por sua vez, a testemunha Tayrine Muquem Mendes e Souza, relatou que, no período que trabalhou no CAPS era técnica de referência da vítima; tentaram fazer contato com o réu diversas vezes para que ele levasse o benefício da vítima, contudo não tiveram sucesso; a vítima sempre solicitava, pois queria comprar coisas pessoais; conseguiram contato pouquíssimas vezes; o réu mudou de endereço e, então, não mais tiveram contato; outras colegas que conseguiram conversar com o réu; não tem conhecimento do destino do benefício.

Destarte, embora não conste na capitulação da denúncia o delito previsto no artigo 168, §1º, inciso II, do Código Penal, a narrativa feita pelo autor da ação descreve que o réu apropriou-se “de coisa alheia móvel” em virtude de sua função de “curador”. Ressalta-se que a capitulação feita pelo autor da ação penal não vincula o magistrado, sendo perfeitamente aplicável, no presente caso, a “emendatio libelli”, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal. Alerta-se que não houve nenhum prejuízo ao réu, uma vez que este se defendeu dos fatos e não de sua capitulação jurídica.

Ademais, em alegações finais o Ministério Público menciona o dispositivo aplicável ao caso em exame (art. 168, §1º, II do CP), revelando que a referência ao §2º na denúncia se trata de mero erro material.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois restou devidamente delineado, através da prova oral colhida e substrato probatório carregado aos autos, que, de fato, o acusado, curador e irmão da vítima, apropriou-se de coisa que não era de sua propriedade, isto é, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) de A.B.deS., correspondente ao valor total de R\$ 13.634,00 (treze mil seiscentos e trinta e quatro reais), sacados pelo réu entre 01/01/2020 e 31/01/2021. Sobreleva notar que, o depoimento da vítima, bem como das testemunhas se revelam harmônicos entre si, e o conteúdo das afirmações está em consonância com os depoimentos prestados na fase inquisitorial e, sobretudo, não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu.

Ensina o ilustre Des. Guilherme de Souza Nucci que “(...) deve o agente responder por uma pena mais grave, concretizada pelo aumento de um terço (...) se o autor recebeu a coisa na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário e depositário judicial; afinal, são pessoas que, como regra, recebem coisas de outrem para guardar consigo, necessariamente, até que seja o momento de devolver. Por isso, devem responder mais gravemente pela apropriação. O rol não pode ser ampliado (...)” (Curso de Direito Penal: Parte Especial: Arts. 121 a 212, do Código Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Ademais, o réu praticou por treze vezes o delito de apropriação indébita, em continuidade delitiva, nesses moldes, de acordo com o artigo 71, “caput”, do Código Penal, aquele que mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Ainda, não há que se falar da inaplicabilidade da revelia, pois como bem anotado por esta magistrada (fls.128/129) “(...) diante da ausência do réu que, apesar de devidamente orientado a retornar à audiência, não o fez, bem como de que, aparentemente, não possui qualquer problema técnico em participar do presente ato, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal, decreto sua REVELIA.

(...).” Em que pese a alegação da d. defesa de que seria demonstrado, em juízo, a inocência do acusado, mediante documentos da suposta residência que o réu estaria construindo para a vítima, não foi carregada aos autos quaisquer comprovações para rechaçar as provas da acusação, salientando-se, também, que caso assim fosse, o

rêu, teria atendido as orientações e retornado a audiência.

Por fim, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Assim, de rigor a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 168, §1º, inciso II, c.c. artigo 71, "caput", ambos do Código Penal. Destaca-se que em alegações finais, o Ministério Público requereu a aplicação de tal causa de aumento, mencionando expressamente o dispositivo aplicável.

Em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e é adotado pelo Código Penal no artigo 68, passo à dosimetria da pena. Primeiramente, atenta aos requisitos constantes no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu não ostenta maus antecedentes, não havendo nada a valorar quanto à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos e às circunstâncias do crime. Todavia, no tocante às consequências do crime, eis que afirmo que fora exacerbada, pois a vítima passou por necessidades diante da falta do repasse do Benefício de Prestação Continuada, não conseguindo comprar itens pessoais e de asseio pessoal, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/8, e fixo a pena-base em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem causas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Existente, contudo, a causa de aumento prevista no inciso II, § 1º, do artigo 168, do Código Penal e a causa de aumento do artigo 71, "caput", do mesmo diploma legal. Logo, majoro a pena em 1/3, dado que o acusado se apropriou dos valores lhe confiados em razão de sua condição de curador, resultando em 01 ano e 06 meses de reclusão e, posteriormente, em 2/3, visto que o crime foi praticado de maneira continuada, ou seja, por treze vezes, fixando a pena definitiva em 2 anos, 06 meses de reclusão, e 18 dias-multa.

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.

O crime imputado ao réu foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Entendo que a substituição da pena é medida socialmente recomendável, de modo que, nos moldes do artigo 44, "caput" e § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, vigente à época do delito, em favor da vítima, sem prejuízo da pena de multa imposta, bem como prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da privativa de liberdade. Justifica-se a substituição por duas restritivas de direitos em virtude do lapso temporal da pena substituída. Cabível a substituição da pena, nos termos artigo 44 do Código Penal, não há que se falar em suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALEXANDRE BERNARDES, à pena de 2 anos, 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, "caput" e parágrafos, do Código Penal), por ser incurso nas sanções do artigo 168, §1º, inciso II, c.c. artigo 71, "caput", ambos do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, vigente à época do delito, em favor da vítima, e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo lapso temporal da pena privativa de liberdade.

O réu responde ao processo solto e poderá recorrer em liberdade, diante da ausência dos requisitos para a decretação de prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processual Penal, até por conta da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Fixo valor mínimo para reparação à vítima em R\$ 13.634,00, a ser atualizado pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do recebimento de cada parcela do benefício. Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se à atualização da pena de multa, intimando-se a seguir o réu para o

respectivo pagamento, nos termos do artigo 50, do Código Penal e artigo 686, do Código de Processo Penal;
Anotar-se a suspensão dos direitos políticos do réu, a teor do inciso III, do artigo 15, da Constituição Federal;
Oficiar-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;
Expedir-se guia de execução penal.
Expedir-se certidão de honorários, se o caso.